

1500153-31.2022.8.26.0537

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: CECÍLIA NAIR SIQUEIRA PRADO EUZEBIO

Comarca: Diadema

Foro: Foro de Diadema

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 06/06/2022

... antecedentes, um deles específico pelo tráfico de drogas, como acima mencionado. Logo, não preenche o requisito objetivo para a concessão desse benefício. A propósito:

"APELAÇÃO - TRÁFICO DE DROGAS - Preliminar - Quebra da cadeia de custódia -

Ausência de materialidade - Inocorrência - Preliminar rejeitada - Mérito - Redução da pena-base - Inviabilidade - agente portador de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Diadema

Foro de Diadema

1ª Vara Criminal

Av. 7 de Setembro, 399, Diadema - SP - cep 09912-010

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500153-31.2022.8.26.0537 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500153-31.2022.8.26.0537 2022/000150

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DIEGO PEREIRA DA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CECÍLIA NAIR SIQUEIRA PRADO EUZEBIO

Vistos.

DIEGO PEREIRA DA SILVA, qualificado à fl. 15, foi denunciado como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, porque, no dia 21 de janeiro de 2022, por volta das 11h00, na Travessa Amazonas, altura do nº 100, Taboão, nesta cidade e Comarca de Diadema, trazia consigo, para fins de mercancia e entrega a terceiros, 64 porções de "crack", com peso de 10,29g., 39 porções de cocaína, pesando 31,08g., e 20 porções de maconha, com peso de 96,01g., substâncias entorpecentes que determinam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

O réu passou por audiência de custódia às fls. 66/68, ocasião em que sua prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva.

Notificado (fl. 119), apresentou defesa prévia às fls. 123/125 e a denúncia foi recebida em 17/03/2022 (fls. 134/135).

Houve a citação (fl. 155) e, após, realizou-se audiência telepresencial, nos termos do Comunicado CG nº 284/2020, ocasião em que foi ouvida uma testemunha policial, interrogou-se o réu e procedeu-se com a gravação dos debates orais entre a acusação e a defesa.

Em alegações finais, a D. Promotora de Justiça requereu procedência do pedido,

condenando-se o réu nos termos da denúncia, sob o argumento de que estariam bem provadas autoria e materialidade delitiva. No tocante à dosimetria, requereu o aumento da pena-base em razão da quantidade e natureza do entorpecente. Na segunda etapa, requereu o afastamento da confissão, não realizada nos autos. Pugnou o estabelecimento do regime inicial intermediário, sem a possibilidade da substituição da pena corporal por restritivas de direitos, com a reversão da quantia apreendida em favor do Funad.

A D. Defesa, por sua vez, postulou a absolvição do réu, sob com fundamento na insuficiência do conjunto probatório, aduzindo que não foi realizada campana, nenhuma outra pessoa foi levada à delegacia, tendo ao menos seis policiais participado da diligência e somente um trazido a juízo para dar sua narrativa. Em caso de condenação, requereu a desclassificação para a conduta de porte de drogas. Pugnou, subsidiariamente, a fixação da pena-base no piso legal, afastando-se os maus antecedentes por já fulminados pelo prazo depurador. Requereu a aplicação do privilégio, o estabelecimento do regime aberto, a detração do tempo que o réu está preso para fixação de regime prisional mais brando, deferindo-se ao réu o direito de apelar em liberdade.

É o relatório. Fundamento e decido.

Presentes os pressupostos processuais. Ausentes nulidades a sanar ou preliminares a analisar, passo ao mérito.

O conjunto probatório constante nos autos demonstra a veracidade dos fatos narrados na denúncia, com a necessária segurança e certeza, para que seja julgado procedente o pedido condenatório.

A materialidade delitiva restou comprovada pelo teor do boletim de ocorrência (fls. 05/08), do laudo de constatação (fls. 30/31), do auto de exibição e apreensão (fl. 33), do laudo de exame químico-toxicológico (fls. 110/112) e da prova oral.

Também a autoria restou devidamente comprovada. Senão vejamos.

Interrogado em Juízo, o réu inicialmente informou que é dependente químico, fazendo uso de "crack". Nunca fez tratamento, mas estava previsto para ir a uma clínica quando foi preso. No tocante aos fatos, sustentou ter sido abordado por outros policiais, não por aquele que se manifestou em audiência, estando apenas em poder de 04 papelotes de pedra no bolso e uma maconha, que tinha acabado de pegar. Depois chegou outra equipe, tais policiais entraram no imóvel, saíram e começaram a lhe perguntar a quem seria o traficante que estava no local, mas permaneceu calado. Devido a droga que estava em seu bolso e por ter passagem, o policial disse que lhe forjaria o flagrante, pois teria uma bolsinha com drogas dentro da viatura. Depois saíram outros policiais desse imóvel, com uma sacola na mão, e pediram para que falasse onde o "Orelha" estava e como ele chegava ao local. Permaneceu calado e os policiais perguntando se trocaria sua liberdade pela desse rapaz. Com ele, só foi pego o telefone e a maconha. Não estava com o restante das drogas e nem com o dinheiro. A residência fica perto de um bar, mas é uma residência vazia. Os policiais sempre vão até essa residência. Questionado se sabia de onde os policiais encontraram a droga, disse que eles entraram na casa, depois em uma viela, onde há várias casa e vieram com uma sacola nas mãos. Melhor esclareceu que havia cerca de dez policiais, uma equipe entrou na casa, depois saíram e entraram em uma outra viela, na qual havia várias casas, e dessa viela saíram com a droga na mão. Não conhecia o policial que depôs em audiência e tampouco conhecia os outros policiais que estavam no local dos fatos que teriam participado da abordagem.

Tal versão, entretanto, além de inverossímil, foi frontalmente contrariada pelos demais elementos de prova, que se revelaram suficientes para demonstrar a prática do crime pelo réu.

Com efeito, em depoimento bastante seguro prestado a este juízo, a testemunha Anderson Santiago de Carvalho, policial militar, afirmou que o local dos fatos é conhecido como ponto de tráfico, fazendo parte do ponto de prioridade de patrulhamento da equipe. Em patrulha pelo local, os indivíduos se evadiram e o réu correu para dentro de uma casa carregando uma sacola, cuja cor não se recorda. A equipe foi em seu encalço e localizou dentro do banheiro, onde o réu estava tentando se desfazer dos entorpecentes dentro de um vaso sanitário. Recuperados os entorpecentes, com bastante dificuldade, ele foi conduzido até à Autoridade

Policial. As drogas eram cocaína, maconha e "crack", não se recordando da apreensão de dinheiro. O réu admitiu que estava trabalhando no tráfico por necessitar de dinheiro. Não conhecia o réu antes dos fatos. Outros transeuntes que passavam pelo local foram abordados, mas nada de ilícito foi com eles encontrado. Às perguntas da D. Defensora, respondeu acreditar que cerca de seis policiais participaram da ocorrência, pois houve pedido de apoio, já que na região não é realizado o patrulhamento com uma única viatura, pois a população recebe os policiais com agressividade. Quem visualizou o réu com os entorpecentes foi o depoente e seu companheiro de viatura, tendo o réu sido abordado pela sua pessoa, dentro do banheiro.

Cabe ressaltar, nesse passo, que as palavras do policial, que atuou de maneira tão direta, não podem ser relevadas ou consideradas suspeitas apenas em razão de sua função, pois seria inadmissível que o Estado, que lhe depositou a tarefa de proteção aos cidadãos, desconsiderasse suas palavras justamente quando presta contas de suas diligências.

Por outro lado, é plenamente compreensível o fato de nenhuma pessoa estranha aos quadros policiais ter sido arrolada para testemunhar em desfavor do réu, porque é sabido que em casos de crimes graves, como o tráfico de entorpecentes, a maioria das pessoas evita servir como testemunha, imperando nas comunidades verdadeira "lei do silêncio", temendo sofrer represálias.

Ademais, nada existe nos autos a indicar que o policial estivesse perseguindo o réu ou que tivesse qualquer motivo para incriminar falsamente pessoa que sequer conhecia e que sabe ser inocente. Ressalte-se que o próprio réu confirmou que não conhecia nenhum dos policiais envolvidos na sua abordagem, especialmente aquele que foi ouvido em Juízo. Assim, a credibilidade do testemunho do policial não pode ser afastada.

Por outro lado, as palavras do réu não apresentaram verossimilhança, pois ele se contradisse por três vezes quando mencionou de onde os policiais retiraram a droga, tendo primeiro mencionado que eles disseram que tinham entorpecentes dentro de uma bolsinha, na viatura, depois, ele disse que os policiais teriam saído da casa não habitada com uma sacola com os entorpecentes, e, por último, ele mencionou que os policiais foram pegar a droga em uma viela, próxima a essa casa.

No mais, não é crível admitir que, além de mais de cem porções de entorpecentes variados – o que já seria suficiente para incriminar o réu se realmente os policiais estivessem forjando o crime, o que se admite por hipótese –, os policiais fossem despendar também a quantia de R\$ 301,50, apresentando-a em sede policial, tudo isso para incriminar um inocente. Não há nos autos qualquer justificativa plausível para tanto.

Logo, as palavras do réu não devem prosperar, quer seja pela contradição quer seja por ausência de amparo em qualquer outro elemento dos autos.

Verifica-se, portanto, que a significativa quantidade de droga apreendida em poder do réu (64 porções de "crack", com peso de 10,29g., 39 porções de cocaína, pesando 31,08g., e 20 porções de maconha, com peso de 96,01g.) e as circunstâncias em que se deu sua prisão (policiais estavam em patrulhamento de rotina por local conhecido como ponto de tráfico, quando notaram que o réu, ao visualizar a aproximação da viatura, saiu correndo, carregando algo em suas mãos. Os policiais iniciaram perseguição a pé, quando então o réu adentrou em um imóvel, mas foi abordado em um banheiro, e as drogas recuperadas no interior do vaso sanitário, em uma sacola), evidenciam que, efetivamente, a droga encontrada pertencia a ele e se destinava à entrega a consumo de terceiros, bem caracterizando a prática do crime de tráfico de entorpecentes, mostrando-se impossível, por consequência, a absolvição por insuficiência de provas ou a desclassificação para a prática do artigo 28 da Lei nº 11.343/06.

Cabe ressaltar que a condição de viciado do réu não ficou comprovada nos autos e que a mera alegação de que é usuário não é suficiente para excluir a prática do crime, pois é sabido que usuários de drogas acabam se envolvendo com o tráfico com a finalidade de sustentar o próprio vício. Frise-se, ainda, que a quantidade de droga encontrada em poder do réu é suficiente para afastar a possibilidade de que se tratasse de substância para consumo pessoal.

Assim, não restou configurada nenhuma causa de exclusão de tipicidade, ilicitude ou culpabilidade, havendo provas suficientes para que seja condenado o réu nas sanções do artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06.

Passo, deste modo, à dosimetria da pena, de forma individualizada, com observância ao princípio da humanidade, nos termos do art. 5º, XLVI da CF/88 e arts. 59 e 68, ambos do Código Penal Brasileiro.

Considerando as disposições do artigo 59 do Código Penal, verifico que o réu é portador de três maus antecedentes (autos nº 0008986-67.2008.8.26.0161, com trânsito em julgado para a defesa em 19/07/2010 e extinção da pena por indulto em 11/11/2011 - fl. 105; autos nº 909/2001, referente ao IP nº 138/01, CNJ nº 7001053-10.2002.8.26.0071, com trânsito em julgado para o réu em 23/04/2003 e concessão de indulto em 11/11/2011 - fl. 192; e IP nº 133/2001, referente ao processo criminal nº 352/2001, sendo este específico por tráfico de entorpecentes - fls. 185/186, com trânsito em julgado para a defesa em 02/03/2004 e indulto concedido em 11/11/2011 - fls. 192/193). Culpabilidade normal ao tipo; ausentes elementos para aferir personalidade ou conduta social; motivos, circunstâncias e consequências próprios da conduta.

Por oportuno, anoto que mesmo tendo sido concedido indulto ao réu nas três condenações anteriores, é possível a utilização delas para a configuração de maus antecedentes, já que o indulto não afasta os seus efeitos secundários da reprimenda aplicada.

Assim, considerando a incidência dos três maus antecedentes acima indicados, fixo a pena-base 1/4 acima do piso legal, ou seja, em 06 anos e 03 meses de reclusão, e pagamento de 625 dias-multa, no valor unitário mínimo legal. O dia-multa será à razão mínima ante à situação financeiras do réu, informada em audiência.

Consigno que, em que pese o pedido Ministerial, entendo não ser o caso de elevar a pena-base em razão da quantidade e variedade de drogas apreendidas, pois os montantes totais e os tipos de entorpecentes (123 unidades, dentre elas cocaína, maconha e "crack") não destoam da média das apreensões comumente realizadas nesta Comarca.

Ademais, não prospera a tese defensiva, no sentido de que as condenações supra não poderiam ser utilizadas para o reconhecimento de maus antecedentes, face a ocorrência do período depurador, pois o decurso de tal lapso somente afasta a possibilidade de reconhecimento da reincidência. Nesse sentido, confira-se:

PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS, PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO E USO DE DOCUMENTO FALSO. Pretendido o afastamento dos maus antecedentes.

Descabimento. Critérios de dosimetria de penas que não podem ser considerados ilegais. Adequada exasperação da pena-base diante dos maus antecedentes. Decurso de tempo que não inibe "maus antecedentes". É possível de valoração, como "maus antecedentes", condenações passadas em julgado ou cuja punibilidade fora extinta há mais de cinco anos, posto que o decurso do período depurador apenas inibe o reconhecimento da "reincidência", na dicção do artigo 64 do CP. "Direito ao esquecimento" não reconhecido. Observância ao princípio da individualização das penas. Art. 5º, XLVI. Questão definida diante do julgamento de Recurso Extraordinário com repercussão geral reconhecida, que fixou a seguinte tese: "Não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal." Eventual divergência jurisprudencial que não admite revisão. Improcedência. (TJSP; Revisão Criminal 0010224-02.2020.8.26.0000; Relator Des. Alcides Malossi Junior; 5º Grupo de Direito Criminal; Julgamento: 30/05/2022; Data de Registro: 30/05/2022).

Na segunda fase, ausentes circunstâncias agravantes ou atenuantes a considerar, mantenho a pena inalterada.

Na derradeira etapa, deixo de reduzir a pena com base no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06, uma vez que o réu é portador de três maus antecedentes, um deles específico pelo tráfico de drogas, como acima mencionado. Logo, não preenche o requisito objetivo para a concessão desse benefício. A propósito:

"APELAÇÃO - TRÁFICO DE DROGAS - Preliminar - Quebra da cadeia de custódia - Ausência de materialidade - Inocorrência - Preliminar rejeitada - Mérito - Redução da pena-base - Inviabilidade - agente portador de maus antecedentes - Privilégio -

Impossibilidade - Regime fechado único possível - Recurso desprovido". (TJSP; Apelação Criminal 1500192-86.2021.8.26.0626; Relator (a): Edison Brandão; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Caraguatatuba - Vara Criminal; Data do Julgamento: 16/05/2022; Data de Registro: 16/05/2022).

A pena privativa de liberdade do réu deverá ser inicialmente cumprida em regime FECHADO, o qual se justifica, além da quantidade de pena, também pelo fato dele ser portador de maus antecedentes, sendo um deles específico (artigo 12 da Lei nº 6.368/76), e, especialmente, em razão da quantidade e variedade de drogas, circunstâncias preponderantes à teor do art. 42 da Lei 11.343/06, de forma a afastar a possibilidade de aplicação do regime mais brando, já que este não seria socialmente recomendável.

Impossível, ainda, aplicar disposto no art. 387, § 2º, do CPP, pois, embora se possa saber o tempo que o réu permaneceu custodiado, ou seja, desde o flagrante até a presente, não dispõe esta Magistrada de informações seguras sobre a satisfação dos demais requisitos para a detração da pena ou eventual progressão de regime. Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido e, em consequência, CONDENO DIEGO PEREIRA DA SILVA à pena de 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicial FECHADO, e ao pagamento de 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa, no valor unitário mínimo legal, por infração do artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06. Indefiro ao réu o direito de recorrer em liberdade, pois tal medida é incompatível com o presente decreto condenatório e com o regime fixado para o início do cumprimento da pena. Some-se a isso a gravidade concreta da conduta, ou seja, o porte de significativa quantidade e variedade de drogas, em via pública, e, ainda, o fato do réu ser portador de maus antecedentes, um deles específico por tráfico, tudo evidenciando a necessidade de manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

Havendo recurso, expeça-se a guia de recolhimento provisória e, nada sendo requerido, expeça-se a guia definitiva, arquivando-se, posteriormente, com as cautelas de estilo.

Defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita, observando-se o disposto no art. 4º, §, 9º, "a", da Lei Estadual 11.608/03 e art. 98, §3º, do CPC, especialmente considerando a renda do réu, declarada em audiência, e o fato dele ter tido seus interesses patrocinados pela Defensoria Pública.

Caso não haja recurso desta sentença, oficie-se para destruição das amostras do entorpecente, guardadas para contraprova, nos termos do artigo 72 da Lei nº 11.343/06, cabendo ressaltar que, por ocasião da audiência de custódia, já houve determinação de destruição do entorpecente, reservando-se apenas o necessário à realização do laudo definitivo.

Quanto ao celular Motorola que permanece apreendido nos autos (fl. 34), passados 90 (noventa) dias contados da data em que proferida esta sentença, e não havendo pedido de restituição, caso o bem esteja em boas condições de conservação e utilização, fica autorizada a doação para instituição beneficente, devendo ser apagados os dados pessoais que possam gerar constrangimento e/ou danos à honra e à imagem da pessoa. Tratando-se de aparelho sem valor comercial, fica autorizada a destruição.

Por fim, quanto à quantia de R\$ 301,50 apreendida (fls. 35 e 88), decreto seu perdimento em favor da União. Preceda-se conforme determina o artigo 63 da Lei de Drogas.

Publique-se e intime-se.

Façam-se as anotações e comunicações de praxe.

Diadema, 06 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA